

제61회 2차 디자인보호법 시험 총평

유시훈 변리사

안녕하세요 수험생 여러분, 유시훈 변리사입니다.

시험 치루시느라 정말 고생하셨습니다. 이미 답안지는 제출이 되었습니다. 그러니 시험 생각은 너무 하지 마시고, 휴식기를 가지시면서 재충전의 시간을 가지시길 바라겠습니다.

이번 디자인보호법 시험은 평이한 편이었으나 지엽적인 소논점이 조금씩 존재했던 것으로 판단됩니다. 상중하로 표현하자면, 중중상 정도로 평할 수가 있겠습니다. 문제를 받아 보고 짧은 시간에 검토하여 간략한 총평 및 예상 답안의 목차를 드리오니, 참고용으로 이용해주시면 감사하겠습니다.

[문제 1]

문제 1은 스마트폰 링 판례를 베이스로 낸 문제입니다. 조금 어렵게 느끼셨을 수도 있으실거라 생각합니다.

대법원에서는 본 사건에 대하여 창작비용이성의 무효사유에 근거한 권리남용의 항변에 대하여 판단하는 것이 쟁점이었으나, 잘 아시는 것처럼 창작비용이성이 인정되면서 권리남용의 항변 역시 배척되었던 사건입니다. 그러한 쟁점에 대해서는 설문(3)에만 출제가 되었습니다.

아마 많은 분들이 설문(1), (2)에서 약간 당황하셨을 수도 있을 것 같습니다. 설문(1)과 설문(2)는 위 사건의 하급심(1심, 2심)에서 문제되었던 공동 창작과 부제소특약이 논점으로 출제되었습니다. 공동 창작에 대한 이슈는 1심에서만 다루어졌었는데, 이러한 부분까지 문제를 출제함으로써 난이도를 높였던 것으로 보입니다. 다만, 이미 숙지하고 계신 특허법 내지는 디자인보호법의 내용만을 가지고 논지를 전개하셨어도 크게 문제되지는 않았을 것 같습니다.

설문(1)의 논점은 아래와 같은 것으로 파악됩니다.

- 1) B사가 공동 창작자에 해당하는지 여부의 검토 -> 조건부 해당(판례 충족 시)
- 2) 丙의 최종권리자 乙에 대한 무효 주장 및 조치
- 3) 등록디자인 X와 제품디자인 Y 간의 유사 판단 -> 유사
- 4) 최종권리자인 乙의 丙에 대한 침해 주장 및 조치

1) 설문(1)에 甲이 B사와 제품을 공동 개발하여 디자인 X를 완성하였다는 사정이 있습니다. 실제 사건에서는 1심에서 공동으로 제품에 대하여 논의가 진행된 내용은 인정되지만, 디자인을 완성하는 데 기여한 것은 아니라는 이유로 B사가 디자인 X의 공동 창작자는 아닌 것으로 인정하였습니다. 문제에서는 “공동 개발”이라고만 언급하고 있기에, 甲과 B사가 디자인 X의 공동 창작자라는 전제 하에 문제를 푸셨어도 큰 문제는 없었을 것으로 보입니다. 실제 디자인의 완성에 기여한 사정이 있는 경우에 한하여 등록디자인에 제39조에 따른 무효사유가 존재한다고 언급하셨다면 더 완벽한 답안이 될 수 있으리라 생각합니다.

2) 이에 따라, 丙이 乙에 대하여 검토할 수 있는 조치는 등록디자인 X의 무효심판일 것입니다. 이외에는 디자인보호법상에는 지분이전청구 제도가 없기는 하나 제96조 제1항 본문에 따른 지분이전을 요구할 수는 있을 것으로 보입니다. 또한, 乙이 사업화 중인 사정이 확인되지 않으므로 불필요한 분쟁을 줄이고 사업화가 가능한 권리를 확보한다는 측면에서 丙 입장에서는 실시권 계약을 하는 방법도 있어 보입니다.

3) 양 디자인은 충분히 유사해 보이므로 유사하다는 결론을 내셨을 수 있으리라 판단됩니다. 대법원 내용만 공부하셨더라도 창작비용이성을 판단할 때 추출하였던 구성이 플레이트, 고정부(연결부), 링, 링 하부의 직선 부분이었으므로 이러한 구성들에서 전체적으로 심미감에 차이가 없기 때문에 유사하다고 서술하시면 될 것으로 보입니다.

4) 마지막으로, 아직 무효심결이 확정되지 않았다면 권리는 유효하게 존재하는 것이므로 乙 입장에서는 丙에 대하여 등록 권리에 근거하여 다양한 민/형사상 조치, 권리범 위확인심판 등 다양한 조치가 가능할 것이며, 불필요한 분쟁을 줄이기 위해서 앞서 丙 조치와 같이 지분이전 또는 실시권 유상 계약을 도모하는 방법도 있어 보입니다.

배점이 15점이므로 위 논점들을 적당히 서술하셨다면 충분히 배점을 채우실 수 있으셨을 거라 생각합니다.

설문(2)의 논점은 부제소특약이었고, 乙과 丙이 어떠한 주장을 할 수 있는지 설명하

라고 했기 때문에, 완전히 1심과 2심에서 논쟁된 내용을 물어본 문제입니다. 매우 지엽적인 문제라고 할 수 있겠지만, 리걸 마인드를 가지고 5점 정도의 분량을 적을 수는 있었던 문제가 아닌가 싶습니다.

실제 사안을 들여다보면, 丙은 부제소특약에 근거하여 소의 이익이 없음을 항변하였습니다. 乙은 이에 대하여 부제소특약은 甲과 B사 간의 계약이지 乙과 丙 간의 계약이 아니어서 당사자가 아니라는 이유로 항변이 이유 없다고 주장하였습니다. 그러자, 丙은 甲과 乙은 그 실체가 동일인이며, 丙도 B사로부터 모든 권리의무를 포괄적으로 양수한 자이므로 동일하다는 이유로 부제소특약의 효력이 있음을 주장하였습니다. 실제 판단은, 동일한 자도 아니고, 부제소특약의 내용도 “등록되지 ‘않은’ 지식재산권을 근거로~”라고 되어 있으므로 그 효력이 乙과 丙에게 미친다고 보기는 어렵다고 판단하였습니다.

정리하면, 부제소특약임을 논점으로 뽑아주신 뒤, 丙은 부제소특약을 근거로 소의 이익이 없어 각하되어야 함을 주장함과 동시에, 사실상 계약당사자들과 동일인임을 주장하여 특약의 효력이 미치는 자임을 주장할 수 있습니다. 乙은 이러한 주장에 대하여 계약당사자가 아닌 점, 특약의 내용이 등록되지 ‘않은’ 권리에 근거한 이의 제기를 배제한다는 내용에 불과하다고 항변할 수 있다는 내용을 기재하셨으면 충분하실 것 같습니다.

설문(3)의 논점은 대법원의 내용이죠. 소설문 1)과 2)로 나누어 답하는 방법도 있을 것 같기는 합니다만 소설문 1)의 전단과 소설문 2)가 겹치는 내용이 될 수 있다고 보여지므로 시간 안배를 위하여 권리남용의 항변에 대한 일반적 내용(판례), 법원에서 권리남용의 판단의 전제로 창작비용이성 판단 가부(판례), 창작비용이성의 판단 기준(판례)를 적어주셨으면 될 것 같습니다.

다만, 창작비용이성의 실제 판단을 할만한 사실관계가 주어져 있지 않아서, 실제 대법원 사건에서는 P와 Q가 등록디자인과 다소 차이가 존재하여 창작비용이성이 인정되었다는 내용은 시간이 없으셨다면 배제하여도 무방할 듯 합니다. 창작비용이성의 판단을 위해서는 공지디자인들과 주지 형태인 직선을 결합하여 판단을 해야하는 상황이므로, 일반적인 판단기준에 더불어서, 그 결합의 용이성을 판단하기 위한 판례 “그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 판단한다.”의 내용을 적어주셨으면 더 좋을 듯 합니다.

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재

2. B사가 공동창작자에 해당하는지 여부 - 조건부 적극

- (1) 제3조 제2항 및 제39조
- (2) 공동 창작자 판단기준(판례)
- (3) 사안의 경우

3. 丙의 乙에 대한 조치

- (1) 무효심판
- (2) 기타 조치 - 지분 이전, 실시권 계약

4. 디자인 X와 디자인 Y의 유사 여부 - 적극

- (1) 유사 판단의 일반 원칙
- (2) 사안의 경우

5. 乙의 丙에 대한 조치

- (1) 침해 성립 여부 - 적극
- (2) 사전적 조치
- (3) 민사적 조치
- (4) 형사적 조치
- (5) 기타 조치 - 지분 매매, 실시권 계약(유상)

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재 - 부제소특약

2. 丙의 주장

- (1) 소의 이익 없어 각하
- (2) 계약당사자들과 乙과 丙이 사실상 동일한 자여서 특약의 효력이 있음을 주장

3. 乙의 주장

- (1) 계약당사자가 아니어서 특약의 효력 없음을 주장
- (2) 특약의 내용상 등록된 권리에 기한 주장이어서 내용에 불합치함을 주장

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재 - 창작비용이성, 권리남용의 항변

2. 권리남용의 항변

- (1) 판례의 태도
- (2) 사안의 경우 - 등록디자인 X에 무효사유가 존재하여야 함, 공지디자인들과 주지형태의 결합에 의해 창작비용이성의 무효사유가 있다면 권리남용에 해당 가능

3. 창작비용이성 무효사유가 있는 경우, 법원의 판단 가부 - 적극

- (1) 판례의 태도
- (2) 사안의 경우 - 권리남용 판단 전제로 가능

4. 등록디자인 X의 창작비용이성 판단기준

- (1) 의의 및 취지
- (2) 판단기준(판례)
- (3) 사안의 경우 – 실제 대법원 사건에서는 공지디자인 P, Q에 직선 부분도 없고 소정의 차이가 존재하였고, 창작비용이성 부정되었음을 언급

[문제 2]

문제 2는 구체성 흠결의 무효사유에 대한 일반적인 사례 문제였습니다. 쉬운 문제였다고 생됩니다. 일반적인 침해 상황이 주어지고, 도면의 불일치에 따른 제33조 제1항 본문의 무효사유가 존재하는 경우에 해당합니다.

설문(1)은 甲이 디자인 A를 실시하고 있는 상황이고 침해 주장을 받았기 때문에 등록디자인 B의 소멸에 이해관계가 있는 자에 해당한다는 내용을 적어주시면 됩니다. 적법성 검토에 5점이나 배분되어 있으므로, 무효심판의 의의/취지, 121조 1항, 이해관계인 판례까지 풍부하게 적어주셨으면 됩니다.

설문(2)는 공업상 이용가능성의 단문을 약 10점 가량 풍부하게 적어주시고, 구체성의 측면에서의 의미를 설명하면 더 좋을 듯 하니, 추가적으로 구체성은 권리범위나 심사대상의 특징을 위해서 디자인의 내용이 특징이 되어야 함을 의미한다는 구체성 규정의 취지도 기재해주시면 좋을 듯 합니다. 또한, 대법원 판례에 기초하여 설명하라고 하였으므로, 구체성 판단하는 판례 “디자인등록출원서에 첨부된 도면에 서로 불일치한 부분이 있다고 하더라도 그 정도가 경미하여 그 디자인 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 디자인의 요지를 충분히 파악할 수 있는 경우에는 등록디자인의 권리범위를 특정할 수 있다”를 꼭 기재하셨어야 할 것으로 보입니다.

결론은 불일치라는 내용만 있기 때문에 다소 열린 결말로 내주시면 좋을 듯 합니다. 불일치가 있기는 하나 경미하여 경험칙으로 요지 파악이 가능한 경우와 같이 특별한 사정이 없는 한 무효가 될 것이라고 적어주시면 좋을 듯 합니다.

I. 설문(1)에 대하여

1. 무효심판의 의의 및 취지
2. 청구인 적격
 - (1) 제121조 제1항
 - (2) 이해관계인 판단 기준(판례)

3. 설문(1)의 해결 - 이해관계인 해당

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 공업상 이용가능성의 의미

(1) 의의 및 취지

(2) 요건

(3) 흠결 시 취급

(4) 흠결 유형

3. 구체성 판단 기준

(1) 판례의 태도

(2) 심사기준의 흠결 예시

4. 설문(2)의 해결 - 불일치의 정도에 따라 요지 파악 불가능한 경우에 한하여 무효

[문제 3]

문제 3은 완전히 특허 문제였습니다. 특허법을 열심히 공부하셨다면 비교적 수월하게 풀실 수 있으셨을 거라고 생각합니다.

설문(1)은 권리범위확인심판에서도 실시자가 선사용권의 항변을 할 수 있는지에 대한 논점이었습니다. 특허법에서 준비한 내용으로 기재해주셨으면 됩니다.

설문(2)는 인용심결에 대해서 불복한 경우에 심결취소소송에서 새로운 주장을 하는 것이 가능한지에 대하여 논하는 것이므로 심결취소소송의 심리범위에 대하여 선결적으로 검토해주셨어야 합니다. 당사자계 심판에 대한 취소소송이므로 무제한설에 입각하여 가능하다고 결론을 내신 뒤 어떤 주장이 가능한지를 검토하여야 하겠습니다.

甲의 등록디자인 A가 유사한 선행디자인 X가 존재하는 상황이므로 신규성의 무효사유가 있는 상황입니다. 또한, 디자인 B는 선행디자인 X로부터 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당합니다. 즉, 신규성 무효의 항변, 자유실시디자인의 항변에 대하여 검토하시면 될 것으로 판단됩니다. 배점이 15점이기 때문에, 신규성에 대한 내용도 조금 적어주시면 충분히 풍부하게 채우실 수 있을 것으로 보입니다.

설문(3)은 심결취소판결이 확정된 경우, 필수적 환송이 진행된다는 점(제169조 제2항), 이 때 취소판결의 이유에 기속력이 있는지 여부에 대하여 논하면 될 것으로 판단됨

니다. 배점이 10점이기 때문에 취소판결 이후의 절차, 취소판결의 기속력의 관점에서 논해주신 뒤 사안포섭을 진행해 주시면 될 것 같습니다. 특별한 사정이 없는 한 심결취소판결에 반하는 판결을 할 수는 없기 때문에 최종적으로 설문(2)에서의 항변에 따라 기각심결이 예상된다고 결론내시면 될 듯 합니다.

I. 설문(1)에 대하여 - 생략

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 심결취소소송의 심리범위 - 당사자계는 무제한설

3. 신규성 무효의 항변 가부 - 적극

(1) 판례의 태도

(2) 신규성 인정 여부

1) 의의 및 취지

2) 판단방법

(3) 사안의 경우

4. 자유실시디자인의 항변 가부 - 적극

(1) 판례의 태도

(2) 사안의 경우

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 심결취소판결 이후의 절차

(1) 필수적 환송(제169조 제2항)

(2) 사안의 경우

3. 심결취소판결의 기속력

(1) 의의

(2) 판례의 태도

(3) 사안의 경우

4. 설문(3)의 해결 - 기각심결 예상

[문제 4]

문제 4는 관련디자인에 대한 문제였습니다. 찍히는 논점이었기 때문에 대부분 잘 작

성해주셨으리라 생각합니다. 다만, 설문(1)에서 유사디자인 제도와 차이점에 대하여 논하라고 한 것은 매우 지엽적인 논점으로 보여집니다.

설문(1)에서는 관련디자인의 의의 및 취지, 최근 개정법(3년으로 연장), 관련디자인권의 권리범위에 대하여 먼저 논해주셨으면 좋을 것 같습니다. 유사디자인 제도와 가장 큰 차이와 관련디자인 도입 배경이 결국 독자적 권리범위가 인정된다는 점이기 때문에, 관련디자인권의 권리범위에 대해서 논해주는 것이 중요할 것 같습니다. 이후 유사디자인 제도 하에서는 기본디자인의 권리범위까지는 인정되지 않는다는 점을 주된 차이로 서술 해주시기만 했어도 충분하셨으리라 생각합니다.

디자인 A와 디자인 B의 도면이 주어졌는데, 주어진 취지가 있었을 거라고 생각합니다. 확실하지는 않지만, 기본디자인으로 A가 출원되고 유사디자인으로 B가 출원되어 등록되는 상황을 예시로 가정하여 권리범위를 설명하는 것을 원했던 것이 아닌가 싶습니다. 즉, 기본디자인 A의 권리범위는 디자인 B처럼 좌측판부와 우측판부 모두 반원형의 홈을 지니는 경우까지도 인정되지만, 유사디자인 B의 권리범위는 기본디자인 A처럼 한 쪽 측판부만 반원형의 홈을 지니는 경우까지는 인정되기 어렵다는 식으로 예시를 들었으면 좋은 답안이 될 수 있지 않았을까 싶습니다.

과거에 유사디자인 제도 하에서의 권리범위에 대해서 확인설과 결과확장설의 대립이 있었고 유사디자인 제도는 확인설에 입각하여 해석되던 것을, 2015년에 관련디자인 제도가 도입되면서 결과확장설을 채택한 셈이라는 것으로 더 부연한다면 추가 특점은 가능했으리라 생각합니다.

설문(2)는 최근 개정에서 도입된 제35조 제1항 단서에 대해서 물어본 것으로 판단됩니다. 배점이 6점이나 되므로 관련디자인의 심사등록요건에 대해서 반 페이지 정도의 분량으로 기재하여 주면 좋을 듯 합니다. 이후, 제35조 제1항 단서에 대한 개정 심사기준의 태도도 언급해주시면 좋을 듯 하고, 결론적으로는 관련디자인 출원 후 기본디자인이 소멸하면 관련디자인 역시 등록받을 수 없다고 결론내시면 될 것 같습니다.

추가적으로 단독디자인으로 보정하면 등록이 가능한 점을 언급해주시면서, 다만 기본디자인의 소멸 사유가 제46조 제2항 후단 위반으로 거절이 확정된 경우 등 선출원의 지위가 유지되거나, 기본디자인과 관련디자인 동시에 적용될 수 있는 선행디자인에 따라 추가적인 거절이유가 없는 상황이라면 등록이 가능함을 언급해주시면 더 좋을 듯 합니다.

설문(3)은 선출원주의를 가미하여 출제한 문제입니다. 같은 날 동일인이 유사한 디자인을 각각 단독디자인으로 출원하는 경우에는 제46조 제2항 위반에 해당합니다. 타인이 있다면 협의제였겠지만, 동일인이므로 특허청장에게 선택결과를 신고해야 하는 상황입니다.

다. 따라서, 협의(선택)제에 대한 내용을 서술해주시고, 심사기준에서는 유사디자인이면 관련디자인으로 보정 시 등록 가능하다는 취지를 함께 통지한다고 하고 있기 때문에 이러한 내용도 적어주셨어야 할 것으로 보입니다.

I. 설문(1)에 대하여

1. 관련디자인의 의의 및 취지
2. 최근 개정법의 태도
3. 관련디자인권의 권리범위
4. 유사디자인 제도와 차이
5. 예시를 통한 보완 설명

II. 설문(2)에 대하여

1. 관련디자인의 등록요건
2. 제35조 제1항 단서에 대한 개정 심사기준의 태도
3. 단독디자인으로 보정
4. 설문(2)의 해결 - 등록 불가, 보정하여 등록 가능한 경우 존재

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재
2. 동일인의 동일자 중복 출원
 - (1) 제46조 제2항
 - (2) 선택 절차
 - (3) 흠결 시 취급
 - (4) 유사디자인의 경우 심사기준의 태도
3. 설문(3)의 해결 - 거정무 해당(물품상 심사대상), 관련디자인 보정 시 등록 가능 취지 함께 통지